

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da declaração de nulidade de relação jurídica e danos morais, em face de cobranças indevidas, tendo em vista que este não teria contratado o cartão de crédito com a instituição financeira, sendo assim, vítima de fraude bancária.

A sentença a quo julgou parcialmente procedente os pedidos.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INTERESSE PROCESSUAL E DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA

Cumpra enfrentar, de início, a **preliminar de ausência de interesse de agir** suscitada pelo apelante Banco BMG S.A., que sustenta a necessidade de **prévio requerimento administrativo** como condição para o ajuizamento da presente ação, sob o argumento de que a parte autora não teria buscado previamente os canais internos da instituição para sanar as supostas irregularidades.

A alegação, contudo, não merece acolhimento, por absoluta ausência de amparo jurídico. O ordenamento jurídico pátrio não impõe, como condição de procedibilidade da ação judicial, o prévio esgotamento da via administrativa, salvo nos casos expressamente previstos em lei, o que manifestamente não se aplica à hipótese dos autos.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, prescinde de prévia provocação da esfera administrativa, sendo suficiente a existência de lesão ou ameaça de lesão a direito, conforme expressamente prevê o art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, in verbis:

"A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito."

Com efeito, a simples ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem comprovação de contratação válida, constitui, por si só, lesão atual a direito, apta a ensejar a intervenção jurisdicional, tornando-se inequívoco o interesse de agir

Portanto, ao contrário do que pretende a instituição apelante, não se exige que o consumidor, vítima de descontos bancários não reconhecidos, primeiro questione administrativamente o banco para só então buscar o Judiciário.

Trata-se de direito subjetivo fundamental de ação, que se manifesta com a simples verificação de prejuízo concreto ou ameaça a direito.

Assim sendo, afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, com amparo no entendimento consolidado na jurisprudência pátria, assegurando-se ao autor o pleno exercício do direito de ação constitucionalmente garantido.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Compulsando os autos, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente. Pelo contrário, **sequer requereu a realização de perícia grafotécnica.**

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

DA RESPONSABILIDADE CONSUMERISTA

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que *"A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou"*.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PARTE RÉ. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DETERMINADA A EXCLUSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE

PAGAMENTO. \n1) Trata-se de ação através da qual a parte autora busca a declaração de inexistência dos débitos objetos dos contratos de empréstimo cujas parcelas estão sendo descontadas em seu benefício previdenciário, ao argumento de que nunca o teria contratado, a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais experimentados, julgada procedente na origem.\n2) AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - A relação travada entre os litigantes é nitidamente de consumo, encontrando, portanto, amparo no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, é aplicável à espécie o disposto no artigo 14 do Código Consumerista. A responsabilidade no caso em comento é objetiva, ou seja, independe de prova da culpa do agente causador do dano, uma vez verificada a falha na prestação do serviço. Ademais, incide na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, uma vez alegada a inexistência de relação contratual, incumbe à parte ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.\n3) In casu, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a existência de contratação entre as partes, pois em relação aos contratos juntados aos autos há arguição de falsidade de assinatura, de modo que o ônus de provar a autenticidade da mesma era da parte demandada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC, do qual não se desincumbiu. \n4) Mister ressaltar, ainda, que a parte ré trouxe aos autos comprovantes de transferência dos valores que teriam sido emprestados à autora em que ela mesma figura como beneficiária (evento 9 docs 11, 12 e 16), sendo que até mesmo as telas sistêmicas juntadas no evento 9 docs 13, 14 e 15, não comprovariam a disponibilização das quantias contratadas à autora. \n5) Por outro lado, relativamente ao desconto no valor de R\$ 13,99 (...), referente ao contrato nº 0004996257, como bem reconhecido na sentença, a demandada não acostou nenhum documento possível de aferir que o contrato nº 2146630 diz respeito a tal desconto, motivo pelo qual não é possível atribuir o débito à autora.\n6) Assim, não comprovada a regularidade das contratações, impositiva a declaração de inexistência de débito e a manutenção da sentença. \n7) DANOS MORAIS - Mostra-se evidente que a situação vivenciada pela parte autora, que sofreu descontos em seu benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, gerou-lhe dissabores acima da média e poderia ter sido elidida se os demandados tivessem sido cautelosos ao proceder aos descontos no benefício da parte autora. Nessa esteira, provado então o dano moral deste fato decorrente, tratando-se, pois, de dano in re ipsa.\n8) QUANTUM INDENIZATÓRIO – Valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses similares, O valor fixado na sentença, em R\$ 6.000,00 (...), deve ser mantido. \n9) REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Pelo conjunto probatório produzido nos autos, verifica-se que a demandada não foi prudente, não tendo adotado os devidos cuidados para evitar eventuais cobranças indevidas. Sendo indevidas as cobranças, a devolução das quantias indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora é medida impositiva. Em relação à forma de devolução, passa-se a passo a autorizar a repetição na forma dobrada, tendo em vista a tese definida por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.\n10) SUSPENSÃO/EXCLUSÃO DOS DESCONTOS - a suspensão possui caráter provisório, quando, no caso em apreço, restou reconhecido a ilegalidade dos descontos em sede de cognição exauriente. Ademais, como mencionou a parte autora, não havendo impugnação pela demandada, a suspensão compromete a margem consignável do consumidor, enquanto que a exclusão retira os débitos da folha de pagamento de forma definitiva. Assim, impõe-se reformar a sentença e determinar que os descontos no benefício previdenciário da autora sejam excluídos. \nDUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50044020320208213001 RS, Relator: Nilton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 18/11/2021, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. **Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter apostado sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.** Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019).

E ainda, segue entendimento jurisprudencial de outubro de 2022, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do TJMG:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de procedência. Recurso do Banco. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Apresentação, pela defesa, do termo de adesão. Impugnação da assinatura. Ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento, no caso o réu. Art. 429, II, CPC. Tema 1061 do STJ. Perícia grafotécnica não realizada. Banco que informou ao Juízo não ter mais provas a serem produzidas, não lhe aproveitando a alegação de que não se opunha à realização da perícia requerida pela autora, uma vez que atribuiu a ela o custeio dos honorários periciais. Preclusão operada. Ausente prova segura da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Precedentes. Verba indenizatória bem fixada (R\$ 10.000,00). Devolução dos valores descontados pelo réu, bem como daqueles disponibilizados na conta corrente da autora, admitida a compensação de valores. Restituição de forma simples. Tema 929/STJ (EAREsp 676.608). Modulação de efeitos que afasta a aplicação do Recurso Repetitivo "hic et nunc". Sentença parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10003934520228260483 SP 1000393-45.2022.8.26.0483, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 20/10/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. PARTE QUE APRESENTA O DOCUMENTO COMO PROVA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. - Sendo do credor o ônus de demonstrar a relação jurídica negada pelo devedor, a ele incumbe comprovar a autenticidade da assinatura lançada no documento que

apresenta para se desincumbir de tal encargo, a teor do disposto no artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil. Orientação do STJ em recurso sob a sistemática do artigo 1.036 do CPC, no sentido de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." (REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021) - O desconto indevido no provento de aposentadoria gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua manutenção - Os danos morais devem ser fixados dentro dos parâmetros de punição do ofensor e compensação do ofendido pelos danos sofridos, sem ocasionar enriquecimento ilícito e nem estimulação de repetição do ato do ofensor, tendo em seu vista o seu caráter pedagógico - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). (TJ-MG - AC: 10000221422264001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual não requereu a realização de perícia grafotécnica.

Nesta ordem de ideias, faz necessário frisar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é irrelevante para o deslinde da causa qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, se o mesmo foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Desta feita, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Nesse sentido:

*APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. **1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ).** 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC 14). 3. Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS. 4. Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença em R\$ 3.000,00. 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)*

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra *in re ipsa*, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato de empréstimo consignado sem a devida contratação, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 2. Demonstrada a falha na prestação do serviço, por fraude de terceiros, o consumidor deve ser indenizado pelo dano material sofrido, independentemente de culpa (CDC 14). 3. **Configura dano moral a realização de saques de alto valor na conta de titularidade do consumidor, cujo saldo advinha de benefícios previdenciários pagos com atraso pelo INSS.** 4. **Para o arbitramento do valor de indenização por danos morais, devem ser levados em consideração o grau de lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano. No caso concreto, mantido o valor fixado na r. sentença.** 5. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo. (TJ-DF 07206530620208070003 DF 0720653-06.2020.8.07.0003, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 02/12/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. **DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRA CONTRATUAL.** RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, publicado em 2021-04-13) (grifei)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, mantenho a **condenação do BANCO BMG S.A. ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R\$ 3.000,00 (três mil reais).**

-

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE

PROCEDÊNCIA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELANTE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANOS MORAIS FIXADOS EM R\$ 2.000,00 – MAJORAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM 10% (DEZ POR CENTO) – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que o quantum indenizatório fixado a título de danos morais seria excessivamente diminuto e insuficiente para compensar o abalo moral impingido, impondo-se sua majoração para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados em patamar máximo permitido por lei.

2. Considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, entendo que o quantum indenizatório fixado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se diminuto, impondo sua majoração na hipótese, que, outrossim, não deve ocorrer no patamar requerido pelo apelante, demonstrando-se razoável e proporcional sua fixação no importe de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o patamar consagrado pela jurisprudência pátria em casos similares.

3. Com relação ao pedido de majoração dos ônus sucumbenciais, sem razão a parte autora, uma vez que, estes foram fixados em conformidade com as disposições contidas do art. 85, § 2º do CPC.

4. Dessa forma, a sentença merece reforma, com a majoração do dano moral, passando de R\$ 2.000,00 (dois mil) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se o patamar fixado a título de honorários sucumbenciais, eis que se encontra nos parâmetros do art. 85, § 2º do CPC.

5. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido, tão somente para majorar os danos morais de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002662-76.2019.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/10/2021)

-

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, **estes devem ser devolvidos de forma simples**. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de

cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indêbitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EResp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que **os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021** (extrato ID 28617999) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples, sendo em dobro após esta data.

DO AFASTAMENTO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR

No que tange à condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, imposta na sentença de origem com fundamento no art. 80 do Código de Processo Civil, entendo que tal penalidade não subsiste à luz da correta interpretação do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação processual aplicável.

A sentença considerou que o autor teria agido de má-fé ao incluir, no polo passivo da presente demanda, contratos cuja regularidade veio a ser posteriormente reconhecida judicialmente, inferindo-se, assim, a dedução de pretensão sabidamente infundada.

Ocorre que tal conclusão não se sustenta juridicamente, tampouco encontra respaldo nos elementos probatórios carreados ao feito. A simples ajuização de demanda visando à declaração

de inexistência de débitos referentes a contratos bancários cuja autenticidade e origem são contestadas, sem que haja prévia confissão do autor ou prova robusta de que este tinha plena ciência da legitimidade dos contratos, não caracteriza, por si só, má-fé processual.

Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece, em seu art. 80, um rol taxativo das hipóteses que configuram a litigância de má-fé, dentre as quais destaco:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - altera a verdade dos fatos;

III - usa do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opõe resistência injustificada ao andamento do processo;

V - procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provoca incidentes manifestamente infundados;

VII - interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em nenhum momento, contudo, o autor se enquadra em qualquer dessas hipóteses. Ao contrário, o que se extrai da análise dos autos é a conduta legítima e diligente de um consumidor que, diante de sucessivos descontos em seu benefício previdenciário, de origem duvidosa, socorreu-se do Judiciário para buscar proteção à sua esfera jurídica, exercendo, portanto, direito fundamental de ação, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, cabe destacar que o autor não detinha meios técnicos para aferir, por si só, a autenticidade das contratações supostamente firmadas, especialmente quando se trata de contratos assinados há mais de uma década, em sua maioria formalizados em contexto de elevada vulnerabilidade social e econômica, comum a aposentados e pensionistas.

Logo, diante da ausência de prova inequívoca de má-fé processual, da dúvida legítima acerca da origem dos contratos bancários questionados e da regularidade do exercício do direito de ação, impõe-se o afastamento da penalidade imposta ao autor, por ser indevida, desproporcional e atentatória à boa-fé objetiva processual, prevista no art. 5º do CPC/2015.

Assim, afasta-se a condenação por litigância de má-fé imposta na sentença de origem, excluindo-se a multa processual de 1% sobre o valor da causa, bem como os ônus sucumbenciais decorrentes, por absoluta ausência de dolo, fraude ou intuito temerário por parte do demandante.

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de **dano material** (repetição do indébito) decorrente de **relação extracontratual**, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos **danos morais**, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da **data do arbitramento** (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de **cada desconto indevido** (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Isto posto,

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora para declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação aos contratos nº 218247337, 211980639, 224823940 e 223870017, condenando o banco/apelante à devolução simples do valor indevidamente descontado até 30/03/2021, sendo em dobro após esta data e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Afasto, ainda, a condenação do autor por litigância de má-fé, excluindo-se, por conseguinte, a multa de 1% sobre o valor da causa e os honorários sucumbenciais arbitrados contra si.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do BANCO BMG S.A.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora